

1501145-23.2022.8.26.0559

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Furto

Magistrado: SENIVALDO DOS REIS JUNIOR

Comarca: Palestina

Foro: Foro de Palestina

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VARA ÚNICA DA COMARCA DE PALESTINA

Rua Capitão Faria, n. 1048, Fórum, Centro, Palestina, CEP 15470-000

Horário de atendimento ao público: das 12h30min às 19 horas

DATA: 26 de outubro de 2022

LOCAL: Sala de Audiências

AUTOS Nº: 1501145-23.2022.8.26.0559

JUIZ DE DIREITO: Dr. Senivaldo dos Reis Junior

PROMOTOR DE JUSTIÇA: Dr. Gustavo Yamaguchi Miyazaki (presente)

RÉU: JOÃO VICTOR CASTOR DE OLIVEIRA SANTOS (presente)

ADVOGADO: Dr. Sergio Luiz Cuervo Oliveira Filho (presente)

TERMO DE AUDIÊNCIA – PROCESSO DIGITAL

Iniciados os trabalhos, constatou-se a ausência da vítima, Anésia Bissóli de Souza, embora devidamente intimada (fl. 246).

Após, foram inquiridas as testemunhas arroladas pela acusação Jean Carlos Vieira, Ederson Paulo da Silva e Rodrigo Souza Lopes da Silva e a testemunha arrolada pela defesa Carlos Roberto Dias (nesta ordem). Nas inquirições, as perguntas iniciaram pelo MM. Juiz com a expressa concordância das partes.

As partes desistiram da inquirição da vítima Anésia Bissóli de Souza, o que foi homologado Pelo MM. Juiz.

A seguir, o réu foi interrogado.

O registro da(s) oitiva(s) foi realizado mediante gravação digital (audiovisual), com a aquiescência das partes e testemunhas, conforme permissivo do artigo 405, § 1º, do CPP. Para maior fidelidade, os eventuais compromissos legais, as dispensas de compromisso e as contraditas foram registrados oralmente durante as oitivas. Considerando tratar-se de processo digital, a mídia digital (DVD) com a gravação audiovisual segue o presente termo.

Estando encerrada a instrução, pelas partes foi dito que não tinham diligências complementares a requerer.

Prosseguindo-se aos debates orais, foi dada a palavra às partes, tendo a MM. Juiz facultado às partes a apresentação de alegações em mídia digital, por resumo das teses ou oralmente (com gravação audiovisual).

O representante do Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais em mídia digital (audiovisual).

Na sequência, Pelo MM. Juiz foi preferida a seguinte sentença:

"Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de JOÃO VICTOR CASTOR DE OLIVEIRA SANTOS, já qualificado nos autos, como incurso no caput do artigo 155 do Código Penal afirmando que, em 08 de julho de 2022, por volta da 13h30min, na Rua Capitão Faria, 1650, Centro, nesta cidade e comarca de

Palestina/SP o acusado subtraiu, para si ou para outrem, um botijão de gás vazio, cor cinza, avaliado em R\$250,00 (duzentos e cinquenta reais), coisa alheia móvel pertencente à pessoa de Anésia Bissóli de Souza.

Segundo se apurou no inquérito policial que embasou a denúncia, o acusado dirigiu-se até o local dos fatos e pulou o muro para conseguir ingressar na residência da vítima. JOÃO VICTOR se apossou de um botijão de gás, pulou o muro de volta, e se evadiu carregando a "res furtiva" na garupa de uma bicicleta. Ederson estava próximo à residência da vítima e visualizou o denunciado pulando o muro para ingressar e ao se evadir com o botijão de gás. Levado o fato ao conhecimento da Polícia, o denunciado foi localizado e preso em flagrante, restituindo-se a "res furtiva" à vítima. Por fim, apurou-se que a vítima era maior de 60 (sessenta) anos na data do fato.

A denúncia foi recebida e o processo seguiu seu trâmite natural, com apresentação de defesa prévia, audiência de instrução e julgamento e alegações finais.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

O artigo 155 do Código Penal assim descreve o delito de furto:

"Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel".

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída, para si ou para terceira pessoa.

Trata-se de crime material, que requer o efetivo desfalque do patrimônio da vítima. A consumação do delito ocorre no momento em que a posse da coisa é invertida.

"O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores" (...)

"Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada"

STJ: REsp 1.524.450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, DJe 29/10/2015, Tema 934 dos Recursos Repetitivos).

Ficou comprovada a existência do crime e sua autoria.

A existência do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/3); boletim de ocorrência (fls. 10/13), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14) e, sobretudo, pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

A vítima ANÉSIA BISSÓLI DE SOUZA, na fase policial, disse que "no dia de hoje, por volta das 13:30 horas, estava em sua casa com sua neta, quando um indivíduo de nome Éder (17-988144750), o qual trabalha como vigilante no Fórum de Palestina, bateu palmas em sua casa; Assim que a declarante saiu, Éder informou que viu quando um indivíduo de nome João Victor Castor, parou uma bicicleta perto da casa da declarante, pulou o muro da casa, passou um botijão de gás para fora, pulou o muro de volta e saiu com a bicicleta carregando o botijão de gás; Disse ainda Éder que tentou ir atrás de João Victor para recuperar o botijão de gás, mas o perdeu de vista; A declarante cientificada dos fatos, informou que não autorizou ninguém pegar seu botijão de gás; Éder, por conta própria, já acionou a Polícia Militar que iniciou buscas a localizar João Victor e o botijão de gás. A declarante avisou sua filha, que a buscou e vieram juntas até esta Delegacia para registrar o presente. Acrescenta que olhou em sua casa e não sentiu falta de mais nada além do botijão de gás; Em tempo, antes do encerramento do presente, compareceu novamente a declarante

noticiando que por volta das 17:00 horas, um indivíduo bateu palmas em sua casa dizendo que embora não tivesse sido ele quem furtou o botijão de gás, estava ali para devolver a ela, momento em que ele questionou quem havia acionado a Polícia e acusado ele de ter furtado, tendo a declarante dito que não sabia o nome da pessoa; A declarante reconhece sem sobra de dúvidas o botijão de gás furtado e devolvido em sua casa nesta data, bem como confirma que o indivíduo conduzido pelos Polícias Militares até esta Delegacia é o mesmo que devolveu o botijão em sua casa; Informa ainda que o botijão de gás vazio, custa em média R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)". Em juízo manteve sua versão.

A testemunha de acusação, o policial militar, JEAN CARLOS VIEIRA, na fase policial, disse que "o depoente é policial militar exercendo suas atividades no município de Palestina e hoje estava de serviço com o policial Sd. R.Lopes, quando por volta das 14:20 horas foram acionados para atender local de furto em interior de residência situada na Rua Capitão Faria, 1650, Centro de Palestina. No local conversaram com a vítima ANÉSIA BISSÓLI DE SOUZA, moradora da residência, a qual relatou que hoje, por volta das 13:30 horas, estava em sua casa com sua neta, quando um indivíduo de nome EDERSON, ora testemunha, e que trabalha como vigilante no Fórum de Palestina, bateu palmas em sua casa contando ter visto João Victor Castor parando uma bicicleta perto da casa dela pulando o muro do imóvel, que é baixo. Após João Victor passou um botijão de gás para fora, e pulou o muro de volta saindo com a bicicleta carregando o botijão de gás. Ainda segundo a vítima, a testemunha EDERSON tentou ir atrás de João Victor para recuperar o botijão de gás, mas o perdeu de vista. O depoente então conversou com a testemunha identificada completamente como EDERSON PAULO DA SILVA o qual confirmou a versão da vítima, acrescentando teria visto o furto pois estava sentado no bar defronte a residência. Diante das notícias, o depoente repassou os fatos a toda rede, acrescentando que JOÃO VICTOR é conhecido nos meios policiais como contumaz furtador, inclusive já sendo preso por tais delitos. O depoente e demais policiais da cidade iniciaram diligências visando localizar JOÃO VICTOR, contudo a princípio sem sucesso, todavia por volta das 17:00 horas enquanto patrulhavam no Centro ainda procurando JOÃO VICTOR, ao passarem próximo ao seu Destacamento Policial, observaram que o policial DIAS, o qual esta de folga, estava na companhia de JOÃO VICTOR. Desta forma desembarcaram e abordaram JOÃO VICTOR. Revistado nada de ilícito foi localizado. O policial DIAS informou que estava indo buscar algo em seu veículo estacionado ao lado da Base, momento que viu JOÃO VICTOR passando pela via pública e o chamou, sendo que neste instante a viatura estava passando. JOÃO VICTOR questionado, alegou que realmente tinha furtado o botijão de gás e sabendo que os policiais estavam no seu encalço, devolveu o botijão na residência da vítima momentos antes. Acreditando que tudo estava resolvido caminhava pelo local quando foi chamado pelo policial DIAS. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a JOÃO VICTOR, sendo este conduzido até esta Delegacia, sem uso de algemas. Ainda confirmaram com a vítima que realmente o botijão de gás havia sido devolvido, tendo passado JOÃO VICTOR passado pelo PS local emitindo-se Laudo Medico sem lesões aparentes." Em juízo disse que: "foram informados pelo 190 pelo senhor Ederson que estava próximo a um bar e visualizou o fato, sendo que viu o acusado subindo o muro, e levou da casa da vítima um botijão de gás; fizeram diligências e nada encontraram; ao retornarem à base, foram informados pelo Cabo Dias que ele tinha visualizado João Victor e logo encontraram o acusado, efetuando a prisão; o acusado confirmou o fato, e ainda, disse que teria devolvido o botijão na propriedade da vítima; lembra-se de ter encontrado o acusado por volta das 16:00 horas; não sabe se o acusado ofereceu qualquer tipo de resistência; foi coincidência o acusado estar passando no local e ter sido visualizado pelo Cabo Dias; não sabendo se ele tinha intenção de se entregar. A testemunha RODRIGO SOUZA LOPES DA SILVA, na fase policial, disse que "é policial militar trabalhando nesta urbe. Hoje estava de serviço com o policial Jean, quando por volta das 14:20 horas foram acionados para atender local de furto em interior de residência situada na Rua Capitão Faria, 1650, Centro de Palestina. Lá conversaram com a vítima ANÉSIA BISSÓLI DE SOUZA, moradora do local, sendo que esta contou que hoje por volta das 13:30 horas, estava na casa quando um indivíduo de nome EDERSON, ora testemunha, e que trabalha como vigilante no Fórum de Palestina,

bateu palmas contando ter visto João Victor parando uma bicicleta perto da casa dela pulando o muro do imóvel, que é baixo. Após passou um botijão de gás para fora, e pulou o muro de volta saindo com a bicicleta carregando o botijão de gás. A testemunha EDERSON tentou ir atrás de João Victor para recuperar o botijão de gás, mas o perdeu de vista. Conversaram com a testemunha identificada completamente como EDERSON PAULO DA SILVA o qual confirmou a versão da vítima, salientando ter visto pois estava sentado no bar defronte a casa. Diante das notícias, repassou-se os fatos a toda rede, salientando que JOÃO VICTOR é conhecido nos meios policiais como contumaz furtador. Desta forma iniciaram diligências visando localizar JOÃO VICTOR, contudo a princípio sem sucesso, entretanto por volta das 17:00 horas enquanto patrulhavam no Centro ainda procurando JOÃO VICTOR, ao passarem próximo ao seu Destacamento Policial, observaram que o policial DIAS, de folga, estava na companhia de JOÃO VICTOR. Ato contínuo desembarcaram e abordaram JOÃO VICTOR. Revistado nada de ilícito foi localizado. O policial DIAS informou que estava indo buscar algo em seu veículo estacionado ao lado da Base, momento que viu JOÃO VICTOR passando pela via pública e o chamou, sendo que neste instante a viatura estava passando. Indagado JOÃO VICTOR, este alegou que realmente tinha furtado o botijão de gás e sabendo que os policiais estavam atrás dele, devolveu o botijão na residência da vítima momentos antes. Pensando que tudo estava resolvido caminhava pelo local quando foi chamado pelo policial DIAS. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a JOÃO VICTOR, sendo este conduzido até esta Delegacia, sem uso de algemas. Ainda confirmaram com a vítima que realmente o botijão de gás havia sido devolvido, tendo passado JOÃO VICTOR passado pelo PS local emitindo-se Laudo Medico sem lesões aparentes.". Em juízo acrescentou que: retornou até o local dos fatos; sendo que outra testemunha também viu o acusado pulando o portão, por ser baixo; o portão não passava de 1,5 metro de altura.

A testemunha EDERSON PAULO DA SILVA, na fase policial, disse que "O depoente trabalha como vigilante no Fórum de Palestina. Na data de hoje estava sentado no Bar do "Fubua" o qual fica situado na Rua Capitão Faria, altura do numeral 1600, quando por volta das 14:00 horas, observou um indivíduo que somente conhecia com JOÃO VICTOR, encostando sua bicicleta na guia da calçada. Após descer retornou uns 5 metros a pé na calçada e pulou um muro baixo de uma residência adentrando em seu quintal. Após nem 5 minutos JOÃO VICTOR pulou de volta o muro e colocando o corpo novamente no muro do lado de dentro da residência, trouxe um botijão de gás, o colocando na garupa da bicicleta. Diante do furto o depoente tentou ir atrás de JOÃO VICTOR, todavia não conseguiu acompanhar o perdendo de vista. Acrescenta que o Bar de "Fubua", local onde estava sentado, fica bem defronte a residência da vítima furtada, sendo possível observar bem a ação delituosa. Como não conseguiu recuperar o botijão de gás, o depoente foi até a residência da vítima, a qual conhecia somente de vista e narrou os fatos ocorridos para esta, tendo acionado a polícia militar e também informado os fatos. O depoente aqui presente reconhece sem sombras de dúvidas o indivíduo conduzido pelo policiais militares como o mesmo que viu subtraindo o botijão de gás." Em juízo disse que: "na data dos fatos ele viu o João Vitor pulando a casa da senhora e pulou o muro e adentrou na residência para levar um botijão de gás; estava no Bar do Fubua; verificou que o acusado estava a algum tempo observando a residência para invadir; ele entrou no local pulando um muro; após verificar o furto foi até a polícia para informar o furto; sabe que ele foi encontrado após algumas horas; perseguiu o acusado por um tempo, cerca de 20 min; acredita que o acusado não o viu, mas demorou um pouco do local para ir atrás do acusado; retornou até o local para ver se a vítima tinha dado falta de algo; tinham mais 2 com ele no bar, jogando sinuca, mas não viram o acusado saindo, apenas o acusado saindo de bicicleta; o bar fica do lado do outro lado da rua; acha que o muro tem algo em torno de 1,5 metro de altura."

A testemunha Carlos Roberto Dias em juízo disse o seguinte: "estava de serviço administrativo na base, em razão de licença médica; ouviu comunicação via rádio e grupo dos policiais a respeito de um furto de bujão de gás ocorrido na cidade; foi da base até o seu carro em frente à base, e quando estava retornando ao posto de serviço, viu que o acusado estava em sentido norte da rua; chamou o acusado e o indagou a respeito do botijão de gás; ato contínuo os policiais militares da

diligência chegaram e deram voz de prisão ao acusado; não foi o acusado que procurou a polícia, mas sim foi encontrado fortuitamente; no momento da conversa confessou o delito; disse que teria vendido para Garrote, mas nada falou sobre a devolução.

JOÃO VICTOR CASTOR DE OLIVEIRA SANTOS, em seu interrogatório perante a autoridade policial, disse que "não tem filhos, sua genitora foi avisada de sua prisão. Não tem advogado constituído e não tem como contratar um. Não foi agredido fisicamente e não está machucado. É usuário de crack e maconha. Na data de hoje por volta após o almoço estava passando por uma rua próxima ao cemitério com sua bicicleta quando viu através de um muro baixo de uma residência, um botijão de gás e um carrinho tipo de mudança. Com estava precisando de dinheiro pra sustentar seu vício, decidiu pegar o botijão. Encostou sua bicicleta na guia e depois pulou o muro que é bem baixo pegando o botijão que estava vazio. Retornou com o botijão e o colocou na garupa da sua bicicleta andando até a esquina próxima, onde tem um terreno com mato, deixando o gás naquele local. Saiu e deu volta pela cidade, e aproximadamente uns 20 minutos ficou arrependido, retornou ao terreno, pegou o botijão de gás e foi até a residência onde o tinha subtraído. Neste local chamou moradores e conversou com uma senhora, dizendo que estava arrependido e que estava devolvendo o botijão de gás para ela. Falou ainda que pensou que as coisas estavam abandonadas e por isso havia pego o botijão. Após como tinha já devolvido o gás, foi até o Destacamento da Polícia Militar para contar o tinha feito conversando com o policial DIAS e logo após narrar o que tinha acontecido, chegaram outros policiais militares, dentre eles o policial Jean. Inquirido se tinha conhecimento se havia policiais a sua procura, alega que não, bem com nega que foi perseguindo por popular que havia presenciado o furto". Em juízo disse que: "estava no bar a testemunha Ederson; viu que na área da casa ao lado tinha um botijão de gás e pensou que ele seria jogado fora; saiu da casa e colocou na esquina; retornou até o bar para comprar uma cerveja; o avisaram que o botijão estava amassado e não era coisa abandonada; retornou até a vítima para devolver o botijão; a vítima disse que iria trocar o botijão; pediu desculpas à vítima e ficou sabendo que a vítima e os vizinhos tinham chamado a polícia; apertou a campainha e foi se entregar na polícia militar; ficou aguardando a polícia, visto que tocou várias vezes e ninguém atendeu; inclusive pensou que a casa era abandonada; está arrependido da prática, mas não tinha intenção de furtar.

Sobre o apossamento de coisa perdida, leciona Victor Rios Gonçalves (Direito Penal Esquemático, Parte Especial, item 2.1.1.5) que "as coisas perdidas (res desperdicta) têm dono, contudo, só são assim consideradas aquelas que estão fora da esfera de vigilância do dono porque foram perdidas em local público (ruas, praças, avenidas) ou aberto ao público (estádios, supermercados, metrô, ônibus), já tendo o responsável dali se afastado. Em tais casos, quem encontra o objeto e dele se apodera não realiza ato de subtração, daí porque o legislador, considerando que o bem tem dono, tipificou a conduta como apropriação de coisa achada (art. 169, parágrafo único, II). Quem encontra uma carteira na calçada e fica com ela comete esse crime, caso o dono já não esteja mais no local. Se o agente, todavia, vê que uma pessoa está conversando na mesa de um bar na calçada e que, do bolso traseiro de sua calça, acabou de cair uma carteira sem que ela tenha notado, e ele, sorrateiramente, se aproxima e pega a carteira, comete furto, porque, neste caso, a carteira, embora no chão, ainda estava na esfera de vigilância da vítima. Da mesma forma, quando o dono de um objeto não sabe onde ele está, mas este se encontra dentro de sua casa ou escritório, o bem não se considera tecnicamente perdido. Assim, se a dona de casa não percebeu que seu brinco caiu enquanto ela tomava banho e a empregada, ao limpar o ralo, achou o brinco e o levou embora, esta responde por crime de furto" (grifos originais).

No caso, o produto estava dentro da residência e, portanto, nada é que se falar em produto abandonado na rua, visto que o réu pulou um muro para obter a posse do produto (botijão de gás).

A respeito da insignificância, lembro que o conceito foi introduzido por Roxin em 1964 ("Verwerflichkeit und Sittenwidrigkeit als unrechtsbegründende Merkmale im Strafrecht"), porém tornado célebre em seu "Política criminal e sistema jurídico-

penal”.

A preocupação de Roxin é, a partir da constatação das funções do sistema jurídico-penal extraídas da constituição alemã, estabelecer os limites dos tipos penais; neste contexto, atos que, embora possam se ser subsumidos às proibições da lei penal, mas não impliquem relevante ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma, são materialmente atípicos. Sendo atípicos, nada há de se pesquisar a respeito das condições dos agentes ou do caráter reprovável das condutas.

Não se quer tratar aqui a fonte do jurista alemão como revelação da verdade, mas ressaltar que a introdução do conceito da insignificância está no contexto da teoria do tipo penal, não da sua exegese, de forma que a feição dada pelo Supremo Tribunal Federal difere profundamente da original, notadamente por incluir características ligadas à pessoa do agente (reticência da corte em aplicar o princípio diante de réus reincidentes) e à reprovabilidade do ato (o que diz respeito à culpabilidade ou responsabilidade penal).

Os critérios consagrados pelo STF tentam frear uma distorção originada pelo alargamento do conceito de insignificância pelos tribunais brasileiros que passaram a nele incluir lesões pequenas, mas não irrelevantes, dos bens jurídicos protegidos pela norma penal. Este freio tem uma implicação séria, pois permite que fatos idênticos possam ser considerados típicos ou não a depender da pessoa do agente (p. ex., se ele é reincidente ou não); e, em não se tratando de crimes próprios, esta é a mais terrível feição de direito penal do autor. Não se nega, a propósito, que o nosso sistema penal comporta ainda diversas características do direito penal do autor, mas essa citada, certamente, nele não tem previsão legal.

A fim de evitar tais excessos conceituais, trago os exemplos que Roxin entende como casos de insignificância:

(...) maus-tratos são uma lesão grave ao bem-estar corporal, e não qualquer lesão; da mesma forma, é libidinosa no sentido do Código Penal só uma ação sexual de alguma relevância; é só uma violenta lesão à pretensão de respeito social será criminalmente injuriosa. Por “violência” não se pode entender uma agressão mínima, mas somente a de certa intensidade, assim como uma ameaça deve ser “sensível”, para adentrar no marco da criminalidade.

Assim, vê-se que a insignificância somente exclui a tipicidade material quando, no caso, irrelevante a ofensa ao bem jurídico. É a situação, p. ex., de quem subtrai uma folha sulfite. O fato, a princípio (pela tão só subsunção do fato à letra do tipo penal), é típico, mas a sanção penal deixa de ser devida não por um princípio de interpretação, mas por um princípio penal geral que exclui a tipicidade pela ausência de ofensa ao bem jurídico; afinal, não se pode dizer que a subtração de uma folha sulfite seja capaz de causar um decréscimo patrimonial na vítima.

Todavia, em um país que o salário-mínimo indica que o dia trabalhado vale, ao menos, R\$ 50,00, não se pode entender que o caso presente se trata de insignificância. Isto porque, trata-se de bem essencial e com valor de aproximadamente 30% do salário mínimo.

Sobre o tema colaciono alguns julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR NÃO IRRISÓRIO. MULTIRREINCIDÊNCIA. QUALIFICADORAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte entende não ser possível a aplicação do princípio da insignificância quando a res não apresenta valor irrisório e aos casos de furto qualificado (na hipótese, reconheceu-se a tentativa), a indicar especial reprovabilidade do comportamento, sobretudo quando se trata de agente reincidente, confumaz na prática desta espécie de delito.

2. Inexiste ilegalidade, em face da multirreincidência do réu, no aumento da pena em 1/3, pois a fração mais severa foi devidamente justificada pelo Tribunal a quo, conforme as peculiaridades da agravante genérica.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.971/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA. IMPOSSIBILIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO PACIENTE E OUTRAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR DELITOS PATRIMONIAIS. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA ANTE A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

- A admissão da ocorrência de um crime de bagatela reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem.

- A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve-se levar em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não se deve ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. Precedentes.

- O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar conjuntamente os HC n. 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de Relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, definiu que a incidência do princípio da bagatela deve ser feita caso a caso (Informativo n. 793/STF).

- Por sua vez, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, de minha Relatoria, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação da medida ser socialmente recomendável. Precedentes.

- O fato de o paciente haver tentado furtar, durante o repouso noturno, galinhas de uma residência e, posteriormente, ainda no mesmo dia haver subtraído de outras duas residências - um botijão de gás avaliado em R\$ 80,00 e uma caixa de madeira destinada à produção de mel, avaliada em R\$ 30,00 (e-STJ, fl. 419) -, associado ao fato de ele ser contumaz na prática de crimes patrimoniais, haja vista que além de reincidente específico, também ostenta outras condenações definitivas por delitos patrimoniais, denotam o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, não podendo o Estado beneficiar aqueles que fazem do crime seu meio de vida.

- Desse modo, reputo não preenchido o requisito relativo ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do paciente, não sendo o caso, portanto, de reconhecimento da incidência do princípio da bagatela para absolvê-lo dos furtos perpetrados ante a atipicidade material da conduta.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 751.861/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)

Além disso, pelas condições de fortuna da vítima, não se pode dizer que o dano ao seu patrimônio foi imperceptível.

Na análise da figura privilegiada, vê-se que a lei exige ser o criminoso primário e de pequeno valor a coisa furtada. No caso tem-se que a folha de antecedentes indica que trata-se de criminoso contumaz, inviável a aplicação do benefício.

Configurado, assim, o delito de furto simples, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de (1) um a (4) quatro anos, e multa".

Passo a dosar a pena.

Ressalto que a fixação dos aumentos da primeira fase sobre a pena mínima constitui procedimento contrário à lei. Apesar disso se aplicar a qualquer tipo penal, a contrariedade é notada mais facilmente nos casos em que há grande intervalo entre a mínima e a máxima, quando esta se torna impossível, frustrando a determinação do legislador.

Ora, como o legislador estabelece sempre um mínimo e um máximo, ambos são a medida legal da gravidade do delito, de modo que o procedimento mais adequado para perceber essa grandeza em sua inteireza é levar em consideração justamente o intervalo de pena, ou seja, a diferença entre o máximo e o mínimo legal; aplica-se o aumento sobre o intervalo, adicionando a pena mínima.

É o que recentemente vem fazendo o STJ:

Considerando o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena abstratamente prevista para o delito de sonegação fiscal e a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se afigura desarrazoada ou desproporcional a exasperação da base em apenas 1 (um) ano acima do mínimo legal, porquanto, na compreensão das instâncias ordinárias, suficiente à prevenção e reprovação do crime.

STJ, AgRg no AREsp 1194509/MG, Quinta Turma, rel. Min. José Ilan Paciornik, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018.

A gravidade concreta do delito, praticado por pessoa que é integrante da polícia militar e que mais do que qualquer outro servidor público deve primar pela respeitabilidade de sua instituição e preservar o pundonor que rege a caserna; bem como o modo de execução, tratando-se de delito praticado por meio de grave ameaça e violência moral, justificam a fixação da pena-base 2 anos acima do mínimo legal, tendo em vista o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, que vai de 2 anos a 8 anos de reclusão.

STJ, AgRg no REsp 1678420/PA, Sexta Turma, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018.

Descabe falar em desproporcionalidade na exasperação da pena-base pela culpabilidade, pois, considerando a fração de aumento ideal de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, o qual corresponde a 18 anos, chega-se ao incremento da reprimenda em 2 anos e 3 meses por vetorial desabonadora, ou seja, em patamar inferior ao estabelecido no decreto condenatório.

STJ, HC 448811/PR, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018.

Quanto aos maus antecedentes, descabe falar em desproporcionalidade no aumento da pena em 6 meses, considerando a presença de dois títulos condenatórios a serem valorados na primeira fase da dosimetria, assim como o intervalo do apenamento estabelecido no preceito secundário do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

STJ, HC 451487/MS, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018.

Mantém-se a valoração negativa das vetoriais analisadas pelo v. acórdão impugnado, tendo em vista a fundamentação concreta apresentada, descabendo falar em desproporcionalidade na fixação da pena-base em 5 (cinco) anos e 12 (doze) dias de reclusão, considerando o critério ideal de aumento por circunstância judicial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, o qual corresponde a 6 anos.

STJ, HC 446462/SP, Quinta Turma, rel. Min. Felix Fischer, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018.

Tampouco se faz aqui tarifação de aumentos em tabelas predeterminadas. Além de não haver respaldo legal, isso fere de morte o espírito do Código Penal que estimula a valoração concreta dos elementos do caso.

Segundo o procedimento que valora cada circunstância judicial com um aumento de 1/6 ou 1/8, merecerá a reprimenda máxima o fato criminoso em que estiverem presentes todas as circunstâncias, pouco importando as suas gravidades, ao passo que um fato criminoso envolto em somente uma circunstância negativa, mas presente em um grau absurdo, sofrerá um aumento mínimo.

Ora, isso é uma má interpretação sobre o sistema de imposição de penas estabelecido pela Reforma de 1984 e um descumprimento da Constituição na medida em que esta impõe a individualização da pena, a qual necessita uma valoração da gravidade concreta das circunstâncias, e o art. 59 do Código Penal exige que a fixação da pena atenda à finalidade de reprovação e prevenção do crime, o que também não se alcança com tabelamentos.

Como diz Roberto Lyra nos seus comentários ao Código Penal, a adoção de um sistema de penas inflexíveis estabelece uma igualdade que é a pior das iniquidades. E continua, "a rigor, há arbítrio na lei, no seu apriorismo, na sua abstração, na sua dureza. Nas mãos dos juízes, o texto deixa de ser arbítrio, humanizando-se, sensibilizando-se, adaptando-se à vida e à personalidade de cada homem. Portanto, é a lei que renuncia ao seu egoísmo e vai palpitar, ao ritmo flagrante do convívio social, através da toga. Os mandamentos legais são frios e autoritários. Para o homicídio – de 12 a 30 anos. Por quê? Para quê? Com a liberdade dos juízes responsáveis, não somente em atenção a circunstâncias convencionalmente enumeradas, e sim à realidade integral de cada homem e de cada fato". Para ele, "enquanto se mantiver, com a seleção moral e intelectual, a independência da magistratura, o arbítrio judicial, regulado cautelosamente, como fez o Código, só poderá ser salutar".

Deste modo, o magistrado que fixa os aumentos levando em conta somente o número de circunstâncias e não a suas valorações concretas, age com um automatismo que leva à injustiça e faz pouco de sua toga.

Portanto, o grau do aumento depende mais da intensidade concreta das circunstâncias que da extensão com que são encontradas. Aliás, foi imbuído desse espírito que o STJ sumulou o enunciado 443 para a terceira fase da dosimetria.

Primeira etapa. Ao analisar as circunstâncias judiciais do acusado, anoto que ele apresenta maus antecedentes, conforme certidão de fls. 104/107. Anotando-se que são delitos relacionados ao patrimônio.

O delito foi cometido invadindo uma residência, o que configura uma circunstância especialmente grave. A Constituição protege a casa afirmando a sua inviolabilidade no inciso XI do art. 5º. Ora, uma das funções do direito penal é justamente a tutela de bens jurídicos que aumentam a liberdade e a segurança das pessoas; e uma das facetas importantes dos direitos fundamentais é a criminalização de sua violação. Assim, a violação da residência para a consecução do furto extrapola demasiadamente aquilo que está insito ao tipo penal constituindo circunstância especialmente grave ensejando exasperação da pena próximo ao limite máximo. Aumento, portanto, a pena-se em 10 meses para cada circunstância desabonadora. Fixo a pena base em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa.

Segunda etapa.

A confissão qualificada no presente caso não justifica a atenuante pelos seguintes fundamentos: a) a confissão que não reflete a veracidade não tem o condão de atenuar a pena; b) considerar uma confissão qualificada baseada em tese inverídica gera subversão do próprio sistema de dosimetria; c) se a confissão está estribada em mentira, evidente a inexistência de arrependimento ou contribuição para a verdade dos fatos, não podendo o réu se beneficiar de sua própria torpeza.

Deixo de valorar a confissão, pois, além de qualificada (STF, 1ª Turma, HC 119671/SP, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 05/11/2013, DJe 02/12/2013), não foi necessária à prova da existência do crime e de sua autoria.

Presente a agravante da reincidência (certidão de objeto e pé de fls. 104/107), bem como agravante do delito ter sido cometido em face de pessoa maior de 60 (sessenta) anos, artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, pelas quais aumento a pena em 1/2 (um meio), resultando em 4 (quatro) anos de reclusão e 42 (quarenta e dois)

dias-multa.

Terceira etapa. Ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena.

Inviável o reconhecimento do privilégio.

O furto privilegiado ocorre quando o criminoso é primário e a coisa furtada é de pequeno valor. São requisitos cumulativos, ou seja, os dois devem estar presentes na situação para que possa ser reconhecido o privilégio.

Não há pequeno valor, e tão pouco a primariedade.

Regime inicial de cumprimento. Sendo o réu reincidente, em interpretação "contrario sensu" das alíneas "b" e "c" do §2º do art. 33 do Código Penal, o regime é, necessariamente, o fechado. Além disso, a reincidência constitui valoração gravemente negativa dos antecedentes do réu, que persistiu na vida do crime mesmo após sancionado severamente e, desta forma, nos termos do §3º do art. 33 do Código Penal também merece o regime inicial fechado. A reincidência também impede a suspensão da pena privativa de liberdade por restritivas de outros direitos (não se verificando a exceção do §3º do art. 44 do Código Penal pelo motivo acima exposto) ou a sua suspensão condicional.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR JOÃO VICTOR CASTOR DE OLIVEIRA SANTOS, à pena de reclusão, pelo prazo de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias, em regime inicial fechado, bem como a 37 (trinta e sete) dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no caput do artigo 155 do Código Penal c/c artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal,.

Confirmando-se agora em cognição plena a existência do crime e sua autoria e não se apurando nada que infirme a periculosidade concreta do acusado, as razões de sua prisão cautelar estão mantidas.

"3. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

(...)

5. A técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a sentença condenatória faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva no início do feito, tendo em vista que elas permanecem incólumes."

STJ, Sexta Turma, RHC 86.384/SP, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017.

De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Ademais, conforme preconiza o art. 387, § 1º, do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, "decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar", sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.

Com efeito, a prisão preventiva do acusado está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, principalmente como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, conforme consignado na decisão de fls. 114/117, o acusado é reincidente específico em delitos patrimoniais, com ampla e longa ficha criminal.

Destarte, segundo jurisprudência do STJ, "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro

REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019). IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MAUS ANTECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitativa, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitativa. 4. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitativa e, assim, garantir a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 735.713/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Ademais, a "orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva" (AgRg no RHC 123.351/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 25/8/2020). Na mesma linha: AgRg no HC 563.447/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020; e RHC 119.645/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe 12/2/2020

Pelo mesmo motivo acima delineado, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. Sobre o tema: RHC 91.896/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018; HC 426.142/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 16/4/2018; e HC 400.411/SE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2017, DJe 15/12/2017.

Condeno o(s) acusado(s) ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado advogado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório. Sentença Publicada em audiência. Saem as partes intimadas. Consultadas as partes quanto ao interesse em recorrer, conforme manifestações lançadas ao final da sentença, o Ministério Público informou não ter interesse em recorrer, porém, a defesa manifestou seu interesse em recorrer.

Após, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: "Recebo o recurso interposto pelo réu e pela sua defesa técnica. Dê-se vista à defesa para apresentação das suas razões de apelação. Após, dê-se vista ao Ministério Público para contrariedade. Depois de apresentadas as razões e as contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação do apelo, com as homenagens deste juízo. Ficam as partes intimadas".

Nada mais. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Termo digitado e lavrado por mim, ____ (Antonio Silvio Volpe Sagliocco, Matrícula 94.430-4), Organizador das Audiências. Termo digitalmente assinado pelo magistrado.